SENTENÇA

Processo: 0834070-96.2023.8.19.0002

Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: EM SEGREDO DE JUSTIÇA
RESPONSÁVEL: EM SEGREDO DE JUSTIÇA

RÉU: EM SEGREDO DE JUSTIÇA

ENZO OLIVEIRA DE MELO, representado por ANA PAULA DE OLIVEIRA RODRIGUES MELO, propôs ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais com pedido de tutela antecipada em face de UNIMED SÃO GONÇALO - NITERÓI SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, ambos já qualificados, na qual a parte autora pede, liminar e definitivamente, a continuidade do fornecimento do medicamento CBD 1 PURE 6000mg/30ml, e a condenação em danos morais no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O autor alegou que recebeu diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA), CID-10 F84.0, e foi prescrito pelo médico responsável o tratamento com CBD 1 PURE 3000mg/30ml, medicamento que estava sendo fornecido pela parte Ré desde o ano de 2021. Ainda, narrou que em abril de 2023 fez a solicitação de nova remessa do remédio, obtendo em maio de 2023 negativa do fornecimento e a informação de que a concessão teria sido equivocada.

Diante dos fatos narrados, o autor fundamentou a procedência de seu pedido: a) na taxatividade mitigada do rol da ANS ante a inclusão dos §§ 12 e 13 no art. 10 da Lei nº 9.656/98; b) no art. 6º §4º da Resolução Normativa da ANS nº 465/21, que determina atendimento de método ou técnica indicados pelo médico; c) no afastamento do Tema 990 do STJ, considerando a RDC nº 335/20.

A parte autora juntou documentos no id. 7935153.

Decisão, no id. 79404353, em que este Juízo deferiu a gratuidade de justiça e a tutela antecipada de urgência requeridas.

Contestação no id. 83032329, em que a parte Ré pugnou pela improcedência dos pedidos autorais sob os fundamentos: a) ausência de cobertura para fornecimento de medicamento domiciliar, importado e sem registro na ANVISA, excluído expressamente de previsão legal; b) o Tema 990 do STJ; c) o Tema 550 do STF; d) o disposto no art. 10, I, V e VI da Lei 9.656/98; e) a Resolução Normativa nº 465 da ANS, que exclui o fornecimento de medicamentos importados e não registrados, e de uso domiciliar, conforme seu art. 17, p. único, inc. V e VI; f) a taxatividade do rol da ANS como regra, conforme EREsp 1886929/SP.

A parte ré juntou documentos no id. 83032329.

Petição, no id. 83039924, na qual a parte ré comunicou o Juízo sobre a interposição de agravo de instrumento.

Réplica à contestação, no id. 92244527, na qual a parte autora alegou, em suma: a) a existência de evidências clínicas para o tratamento; b) o histórico do fornecimento anterior; c) os impactos positivos no tratamento com o remédio; d) o princípio constitucional do direito à vida e à saúde, previstos no art. 5º da CRFB; e) a necessidade de manutenção da estabilidade do paciente; f) a expectativa legítima, liberalidade, boa-fé e confiança da continuidade do fornecimento; e, após, reiterou os argumentos da inicial.

Intimadas, as partes informaram não ter provas a produzir, nos ids. 100340528 e 101323783.

Petição da parte ré, no id. 101716504

Parecer do Ministério Público no id. 145756636, no sentido da improcedência do pedido autoral.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Inicialmente, a parte autora se enquadra no conceito de consumidor do art. 2º do Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que se trata de destinatária final, ao passo que a empresa ré, pessoa jurídica de direito privado, conforme sua qualidade de fornecedora de serviços, incide no art. 3º do CDC.

Nesse sentido, resta nítida que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo o regramento do CDC. Com efeito, o art. 6º, VI do CDC dispõe quanto ao direito do consumidor de reparação de eventuais danos sofridos em razão dos serviços prestados pela parte ré.

Acrescido a isso, a norma estabelecida pelo art. 14 do CDC prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços pela reparação dos danos causados aos consumidores decorrentes da própria prestação do serviço, in verbis:

> Art. 14. O fornecedor de serviços responde, **independentemente da existência de culpa**, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (...) § 3° O fornecedor de serviços **só não será responsabilizado** quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Portanto, a responsabilidade civil é decorrente da demonstração, de forma indubitável, da existência do dano de ordem patrimonial, moral, individual, coletivo ou difuso sofrido, assim como da atividade desempenhada pela parte ré e a relação de causa e efeito entre uma e outra, denominada de nexo causal.

Assim, ante a incidência do regramento consumerista, o fornecedor será obrigado a responder pela inadequação dos serviços prestados de forma danosa ao consumidor sempre que presente a conduta, o dano e o nexo causal, dispensada qualquer comprovação de elementos subjetivos.

Ressalta-se que, demonstrada a falha do serviço, o fornecedor só não será responsabilizado quando provar que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou se evidencia a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, §3º do CDC.

No caso dos autos, o autor pretende a condenação da ré ao fornecimento de medicamento CBD 1 PURE 3000mg/30ml para o tratamento de seu Transtorno do Espectro Autista (CID 10 F84), considerando ter ocorrido ilegalidade na interrupção do fornecimento do medicamento prescrito pelo médico responsável.

A parte Ré busca se desincumbir alegando que não há obrigação no fornecimento do referido remédio, tratando-se de medicamento de uso domiciliar não incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e não registrado pela ANVISA.

Com relação à temática, a Lei nº 9.656/98 dispõe sobre planos e seguros privados de assistência à saúde, a qual prevê no art. 10 o plano de referência de assistência à saúde, com exigências mínimas dispostas no art. 12 do mesmo diploma. O artigo 10 da Lei 9.656/98 se ocupa de descrever as exceções prestacionais em seus incisos, e os §§1º e 4º buscam determinar à ANS o dever de regulamentação da amplitude das coberturas que devem ser realizadas pelas operadoras de saúde.

A partir disso, a Resolução Normativa ANS nº 465/21 atualiza o rol de procedimentos e eventos em saúde e dispõe sobre a cobertura assistencial obrigatória dos planos de saúde. De fato, o seu art. 6º prevê no §4º a necessidade de cobertura dos procedimentos que englobem o tratamento dos beneficiários que sejam portadores de transtornos do espectro autista, situação que gera o dever do atendimento de método ou técnica indicada pelo médico assistente, conforme RN nº 539/22.

Acrescido a isso, ainda na referida resolução normativa, o art. 8º, inc. III, prevê a cobertura de medicamentos, desde que regularizados e/ou registrados na ótica nacional. Além disso, o art. 17, que se ocupa do plano-referência, dispõe no parágrafo único sobre as possíveis exclusões assistenciais de medicamentos, a qual colaciono ante a pertinência:

> Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.
>
> Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:
>
> I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental, isto é, aquele que:
>
> a) emprega medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não registrados/não regularizados no país;
>
> b) é considerado experimental pelo Conselho Federal de Medicina – CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia – CFO ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do procedimento; ou
>
> c) faz uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24;
>
> (...)
>
> V - fornecimento de medicamentos e produtos para a saúde importados não nacionalizados, isto é, aqueles produzidos fora do território nacional e sem registro vigente na ANVISA;
>
> VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;
>
> (...)

Notadamente, alguns medicamentos encontram-se previstos na listagem da ANS, conforme se verifica no art. 18, inc. IX e X, e art. 19, inc. V, 'b', 'c', VIII, IX, X 'c', tudo previsto na RN 465/21, consoante o dever de regulamentação da matéria.

Portanto, verifico que: A) as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a incluir, no plano de assistência, tratamentos clínicos experimentais, ou seja, o fornecimento de medicamentos não registrados ou regularizados no país, considerados experimentais pelo CFM, ou em uso distinto ao previsto em sua bula "off-label".

Outrossim, também noto que: B) as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas ao fornecimento de medicamentos importados e não nacionalizados, ou seja, sem registro vigente na ANVISA. Além disso, também não há: C) o dever de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar, prescritos pelo médico assistente para serem utilizados fora do ambiente da unidade de saúde.

No âmbito judicial, no Tema 990 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), restou fixada a tese de que **"As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA"**, tendo em vista, em síntese, do art. 10, V da Lei nº 9.656/98, a previsão de sua exclusão no regulamento normativo da ANS e a infração de natureza sanitária decorrente da importação sem prévio registro.

Assim, com relação às hipóteses “A” e “B”, entendo que não há previsão legal de fornecimento de medicamentos experimentais, bem como medicamentos importados e sem registro vigente na Agência, pelas previsões acima expostas.

Em junho de 2022 a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do EREsp 1.886.929/SP, destacou que a taxatividade do rol de procedimentos da ANS seria regra, cabendo sua mitigação em determinados cenários, sob pena de desvirtuação da sua própria função. Assim, não há, em regra, obrigação em a arcar com tratamentos que não estejam previstos no rol da ANS, caso previsto outro eficaz, efetivo e seguro já incorporado, sendo possível a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimentos além do previsto, e possível a mitigação do rol nos casos de inexistência de substituto terapêutico, bem como esgotamento dos procedimentos previstos no rol.

Com efeito, diante da alteração proveniente da Lei nº 14.454/22, em setembro de 2022, foram incluídos os §§ 12 e 13 no art. 10, os quais estabelecem critérios para a cobertura dos procedimentos não previstos no rol da ANS, caracterizando, portanto, um rol exemplificativo com condicionantes. Senão vejamos:

> § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)
>
> § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)
>
> I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)
>
> II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. (Incluído dada pela Lei nº 14.454, de 2022) (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2022/Lei/L14454.htm#art2)

Notadamente, no caso dos autos, o autor busca a condenação do plano de saúde a proceder com o fornecimento de medicamento de uso domiciliar, fora da unidade de saúde, não consistente em fármaco listado pelo rol da ANS e sem possuir cobertura contratual firmada com a operadora de saúde.

Portanto, entendo se tratar de hipótese distinta da cobertura de tratamento por meio de procedimentos clínicos prescrito pelo médico assistente.

Assim, o bem pretendido, medicamento de uso domiciliar, comporta entendimento que prescinde de verificação da taxatividade do tratamento, tendo em vista que o custeio de medicamentos pela operadora de saúde encontra-se expressamente excluído na RN 465/21 da ANS, e no art. 10, VI da Lei 9.656/98.

Neste sentido, compreendo que o referido artigo é cristalino ao pontuar que o fornecimento de medicamentos de uso domiciliar é exceção à regra das exigências mínimas de cobertura, sendo possível a exclusão de sua assistência pela operadora de saúde, conforme sua análise negocial. Assim, não verifico plausível qualquer interpretação que mitiga o rol de excepcionalidades previsto nos incisos do art. 10 da Lei 9.656/98 e art. 17, p. único da RN 465/21.

É dizer, a aplicação da mitigação do rol de procedimentos é referência ao caput dos diplomas referidos, não sendo possível mitigar a exceção prevista pela própria norma, o que geraria uma interpretação contra a lei e desvirtuaria a lógica do diploma.

Com base nisso, verifico entendimento de ser lícita a exclusão da cobertura, ressalvados antineoplásicos orais (e correlacionados), bem como a medicação assistida (home care), incluídos no rol e que não são objeto dos presentes autos.

Colaciono pertinentes julgados do STJ:

> AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. MEDICAMENTO. ANVISA. REGISTRO. AUSÊNCIA. IMPORTAÇÃO. AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL. DISTINGUISHING. DEVER DE COBERTURA. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. DESCARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. SITUAÇÃO. HOME CARE. CONVERSÃO. INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CUSTEIO. OBSERVÂNCIA. 1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela Anvisa (Tema Repetitivo nº 990 do STJ). 2. Em caso de medicamento sem registro cuja importação foi autorizada pela Anvisa, a exemplo de fármaco à base de canabidiol, este Tribunal Superior tem promovido o distinguishing. 3. A autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio do paciente, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/1977 e art. 12, c/c art. 66, da Lei nº 6.360/1976. **4. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim (arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN-ANS nº 338/2013 - atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN-ANS nº 465/2021).** 5. A medicação intravenosa ou injetável que necessite de supervisão direta de profissional habilitado em saúde não é considerada como tratamento domiciliar (é de uso ambulatorial ou espécie de medicação assistida). (...) (AgInt no REsp n. 1.873.491/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.) Grifei
>
> RECURSO ESPECIAL Nº 2129312 - SP (2024/0082623-4) DECISÃO (...) Da leitura dos autos, verifico que o Tribunal de origem decidiu de forma contrária ao entendimento deste Superior Tribunal de Justiça (...) Na hipótese, a parte autora pleiteia a condenação da parte ré ao fornecimento de "Canabidiol HealthMeds 6000mg, 3 frascos por anos, de acordo com a prescrição médica", bem como indenização por danos morais. Ressalta-se que consta, de maneira expressa, no acórdão recorrido, que **o tratamento pleiteado pela parte autora é de uso domiciliar**. **Em que pese o Tribunal de origem ter analisado a questão do custeio do medicamento à luz da taxatividade ou não do rol da ANS (EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP - DJe de 3/8/2022), saliento que esta Corte possui entendimento pacificado de que a cobertura de medicamentos para uso domiciliar não antineoplásicos não é**

obrigatória, em razão de expressa previsão legal. **Com efeito, consoante disposição contida no artigo 10, VI, da Lei n° 9.656/98, o plano-referência não é obrigado a custear o "fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12", que versam sobre medicamentos antineoplásicos, ou tratamento em home care.** Confira-se: Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto: VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas 'c' do inciso I e 'g' do inciso II do art. 12; Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: I - quando incluir atendimento ambulatorial: (...) c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes; II - quando incluir internação hospitalar: (...) g) cobertura para tratamentos antineoplásicos ambulatoriais e domiciliares de uso oral, procedimentos radioterápicos para tratamento de câncer e hemoterapia, na qualidade de procedimentos cuja necessidade esteja relacionada à continuidade da assistência prestada em âmbito de internação hospitalar; (...) 3. DA HIPÓTESE DOS AUTOS 20. No particular, conquanto tenha o TJ/RS mencionado a jurisprudência do STJ que "considera legítima a recusa de cobertura pelas operadoras de plano de saúde de medicamentos de uso domiciliar que não sejam antineoplásicos ou de uso em regime de home care" (fl. 409, e-STJ), concluiu que "o dever de cobertura pela operadora do plano de saúde pode exsurgir, ainda que se trate de medicamento de uso domiciliar não previsto no Rol da ANS, caso preenchidos os critérios dos incisos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98" (fl. 410, e-STJ). 21. Infere-se, pois, que deve ser reformado o acórdão do TJ/RS para que seja julgado improcedente o pedido deduzido na petição inicial. (sem destaques no original) Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial e julgo improcedentes os pedidos contidos na inicial. Responderá a parte autora pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do previsto pelo artigo 85, § 2°, I a IV, do Código de Processo Civil, ônus esses suspensos em caso de anterior deferimento do benefício da gratuidade de Justiça. Intimem-se. Brasília, 16 de agosto de 2024. Ministra Maria Isabel Gallotti Relatora (REsp n. 2.129.312, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJEN de DJe 20/08/2024.)

Assim, quanto ao item “C”, entendo que também não ocorreu ato ilícito ou falha nos serviços prestados pela parte ré à parte autora, tendo em vista a inexistência de obrigação legal ou contratual em fornecer o remédio prescrito pelo médico assistente, diante do seu caráter de uso domiciliar, configurando ressalva expressamente prevista no art. 10, inc. VI da Lei 9656/98 e art. 17, p. único, VI da RN 465/21 ANS, a qual não incide a controvérsia da mitigação do rol da ANS.

Por fim, deve-se mencionar que há recente decisão do STJ, na qual a segunda turma reconheceu que a União e estados-membros devem fornecer medicamento à base de canabidiol (CBD) para o tratamento de pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e epilepsia (STJ, REsp 2006118/PE). Portanto, para satisfação do direito do autor, a demanda deve ser ajuizada contra a União ou o Estado do Rio de Janeiro e não contra uma pessoa jurídica de direito privado.

ANTE TODO O EXPOSTO, **JULGO IMPROCEDENTES** os pedidos da parte autora, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, tudo nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

REVOGO, desde já, os efeitos da tutela provisória concedida nos autos.

Intimem-se as partes.

Nada mais sendo requerido, vindo o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

NITERÓI, 23 de janeiro de 2025.

GABRIEL STAGI HOSSMANN
Juiz de Direito

Assinado eletronicamente por: GABRIEL STAGI HOSSMANN
28/01/2025 16:47:01
https://tjrj.pje.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento:

25012816470166200000158442931

IMPRIMIR GERAR PDF